

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4239 -	พนักงานสอบสวน กองปราบปราม	ผู้ร้อง
4240/2542	ผู้ต้องหา	ผู้ร้อง
	ร้อยเอก เพชร หรือ มั่นส พรหม เฝ้า	ผู้ร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 87, มาตรา 150

แม้การที่พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาออกนอกพื้นที่ที่ทำการของกองปราบปรามเพื่อตรวจค้นตามหมายค้นจะเป็นการนอกเหนือจากคำร้องขอฝากขังที่ระบุว่าขอรับตัวผู้ต้องหาไปควบคุมยังที่ทำการของกองปราบปรามเพื่อให้พยานชี้ตัว แต่ก็ยังได้อ้างเหตุที่ต้องขออนุญาตฝากขังด้วยว่า การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอีก 15 ปาก ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวนพยานหรือกระทำการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้นได้ มิได้จำกัดเพียงให้พยานชี้ตัวผู้ต้องหาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการชันสูตรพลิกศพผู้ตายเสร็จแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่ผู้ต้องหาจะร้องขอให้แพทย์ในหน่วยนิติเวชของโรงพยาบาลรามธิบดีตรวจพิสูจน์ศพ เพื่อใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 101 อีกได้เพราะการชันสูตรพลิกศพเป็นการสอบสวนความผิดอาญาอย่างหนึ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 ได้ระบุผู้มีหน้าที่ทำการชันสูตรพลิกศพไว้แล้วคือ พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่กับสาธารณสุขจังหวัด หรือแพทย์ประจำสถานือนามัยหรือแพทย์ประจำโรงพยาบาลถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ใช้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประจำท้องที่หรือแพทย์ประจำตำบลนอกจากนี้มาตรา 151 ได้ให้อำนาจผู้

ทำการชั้นสูตรพลิกศพทำการผ่าศพแล้วแยกธาตุส่วนใดหรือจะให้ส่งทั้งศพหรือบางส่วนไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้ และมาตรา 153 ยังให้อำนาจผู้ชั้นสูตรพลิกศพจัดให้ชุดศพขึ้นเพื่อตรวจดูได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไว้โดยเฉพาะในภาค 2 ลักษณะ 2 หมวด 2 แล้วจึงนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 101 มาอนุโลมบังคับหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2541 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่ 1 ต่อศาลชั้นต้นว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2541 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด ส่งตัวผู้ต้องหาซึ่งร่วมกับพวกกระทำความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกาย ร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ช่มชู้ใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น ร่วมกันฆ่าผู้อื่น ร่วมกันซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือสาเหตุแห่งการตายร่วมกันทำลายเอกสารของผู้อื่น และร่วมกันลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 295, 309 วรรคสอง, 310, 288, 199, 188 และ 335(7) เข้าพบผู้ร้อง ผู้ร้องแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารับตัวผู้ต้องหาไปควบคุมไว้ตามอำนาจฝ่ายทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 46 และตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องการปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณีที่ทหารเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหาในความผิดอาญา พ.ศ. 2498 โดยฝ่ายทหารควบคุมตัวไว้ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2541 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2541 แต่เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จผู้ร้องจึงขอให้ควบคุมผู้ต้องหาไปอีกเป็นครั้งที่ 2 มีกำหนด 12 วัน แต่ผู้ร้องได้รับแจ้งจากฝ่ายทหารว่าผู้ต้องหาถูกปลดออกจากราชการ

แล้ว ฝ่ายทหารไม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องหาไว้ต่อไปและส่งตัวผู้ต้องหาให้ผู้ร้องในวันที่ 11 กันยายน 2541 ผู้ร้องยังสอบสวนไม่เสร็จ เนื่องจากต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอีก 15 ปากและรอผลการตรวจพิสูจน์คราบโลหิตในรถยนต์ของกลาง และผลการตรวจเปรียบเทียบคราบโลหิตจากกองพิสูจน์หลักฐาน จึงขอฝากขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างการสอบสวนต่อไปอีกมีกำหนด 12 วัน นับแต่วันที่ 11 กันยายน 2541 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2541 พร้อมกับขอรับตัวผู้ต้องหาไปควบคุมไว้ยังที่ทำการของกองปราบปรามเนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปให้พยานชี้ตัวในที่ทำการของกองปราบปราม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขังตามขอ และไต่สวนคำขอรับตัวผู้ต้องหาไปขังที่กองปราบปราม แล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องรับตัวผู้ต้องหาไปขังไว้ที่กองปราบปรามมีกำหนด 12 วัน

ต่อมาวันที่ 15 กันยายน 2541 ผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2541 ผู้ร้องดำเนินการสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมและนำผู้ต้องหาออกนอกพื้นที่ที่ทำการของกองปราบปรามโดยผู้ต้องหาไม่ยินยอมเพื่อตรวจค้นตามหมายค้น ซึ่งขัดต่อคำร้องขอฝากขังครั้งที่ 1 และขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87, 89 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 240 ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องปฏิบัติตามคำร้องขอฝากขังครั้งที่ 1 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้พยานชี้ตัวผู้ต้องหาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า พนักงานสอบสวนมีเหตุจำเป็นในการสอบสวน เพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้นไป โดยขอรับตัวไปควบคุมที่กองปราบปราม ส่วนการนำตัวผู้ต้องหาไปนอกพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดี ข้อคัดค้านจึงไม่อาจรับฟังได้ยกคำร้องคัดค้าน

และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2541 ผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ตรวจพิสูจน์ศพนายพลสวัสดิ์ จิราภรณ์ผู้ตายเสร็จแล้ว ศพผู้ตายอาจถูกเผาทำลายไปก่อน ผู้ต้องหาประสงค์จะขอตรวจพิสูจน์ศพผู้ตาย เพื่อหาข้อเท็จจริงและอ้างเป็นพยานหลักฐานของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 101 โดยจะให้หน่วยนิติเวช ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และนางพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ซึ่งเป็นแพทย์ที่เป็นคนกลางไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ว่าใช้นายพลสวัสดิ์ จิราภรณ์หรือไม่ ตายเพราะอะไร บาดแผลใด ตรวจน้ำอสุจิ ตรวจเลือด ตรวจเส้นผม และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายศพและค่าตรวจนั้น ผู้ต้องหาจะเป็นผู้ชำระ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การตรวจพิสูจน์ศพผู้ตายเป็นหน้าที่ของโจทก์จะต้องนำสืบในชั้นพิจารณาอยู่แล้วว่าศพนั้นเป็นผู้ตายจริงจึงจะพิพากษาลงโทษจำเลยได้ กรณีไม่มีเหตุที่ผู้ต้องหาจะขอสืบพยานเพื่อพิสูจน์ศพในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

ผู้ต้องหาอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นทั้งสองคำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ต้องหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคำร้องขอฝากขังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พยานชี้ตัวผู้ต้องหาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เห็นว่า แม้การที่พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาออกนอกพื้นที่ที่ทำการของกองปราบปรามเพื่อตรวจค้นตามหมายค้นจะเป็นการนอกเหนือจากคำร้องขอฝากขังที่ระบุว่าขอรับตัวผู้ต้องหาไปควบคุมไว้ยังที่ทำการของกองปราบปรามเพื่อให้พยาน

ชี้ตัวในที่ทำกรของกองปราบปราม แต่ตามคำร้องขอฝากขังของพนักงานสอบสวนดังกล่าวนอกจากพนักงานสอบสวนจะขอรับตัวผู้ต้องหาไปควบคุมไว้ยังที่ทำกรของกองปราบปรามเพื่อให้พยานชี้ตัวแล้ว พนักงานสอบสวนได้อ้างเหตุที่ต้องขออนุญาตฝากขังด้วยการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอีก 15 ปาก ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวนพยานดังกล่าวหรือกระทำการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้นได้ มิได้จำกัดเพียงให้พยานชี้ตัวผู้ต้องหาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ส่วนคำร้องขอให้หน่วยนิติเวช ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนางพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ตรวจพิสูจน์ศพตามคำร้องของผู้ต้องหาเพื่ออ้างเป็นพยานหลักฐานของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 101 นั้น ก็คือการชันสูตรพลิกศพนั่นเอง ซึ่งตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถือว่า การชันสูตรพลิกศพเป็นการสอบสวนความผิดอาญาอย่างหนึ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ได้บัญญัติผู้มีหน้าที่ทำการชันสูตรพลิกศพไว้แล้วคือ พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ กับสาธารณสุขจังหวัดหรือแพทย์ประจำสถานเอนามัย หรือแพทย์ประจำโรงพยาบาล ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ใช้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประจำท้องที่หรือแพทย์ประจำตำบล นอกจากนี้มาตรา 151 ได้ให้อำนาจผู้ทำการชันสูตรพลิกศพทำการผ่าศพแล้วแยกธาตุส่วนใดหรือจะให้ส่งทั้งศพ หรือบางส่วนไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้ และมาตรา 153 ยังให้อำนาจผู้ชันสูตรพลิกศพจัดให้ชุดศพขึ้นเพื่อตรวจดูได้ซึ่งเป็นวิธีการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้โดยเฉพาะในภาค 2 ลักษณะ 2 หมวด 2 แล้ว จึงนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 101 มาอนุโลมบังคับหาได้ไม่ และข้อเท็จจริงได้ความว่าพนักงานสอบสวนได้ทำการชันสูตรพลิกศพผู้ตายเสร็จแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะดำเนิน

การตามคำร้องของผู้ต้องหาได้ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของผู้ต้องหานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาของผู้ต้องหาทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อำนวยการ เต็มพันธ์-กำพล ภู่อุดแสง-ชวลิต ยอดเนร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การควบคุมหรือขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(21)(22) เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในช่วงก่อนการพิจารณาคดีของศาล กล่าวคือ หลังจากผู้ต้องหาถูกจับและได้รับการแจ้งสิทธิแล้วจะถูกลงควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจ หรือในความควบคุมของพนักงานสอบสวนรวมแล้วไม่เกิน 3 วัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน และเพื่อให้ความคุ้มครองต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ส่วนรวมซึ่งมีความจำเป็นต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมาปรากฏในการพิจารณาคดีของศาล ตลอดจนรับโทษหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดจริงจึงจำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาไว้เพื่อป้องกันมิให้หลบหนีหรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายต่อสังคมขึ้นอีก ทั้งนี้เท่าที่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีและไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นจะได้รับการปล่อยชั่วคราวตามกฎหมาย เดิมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสาม ให้อำนาจพนักงานอัยการหรือ

พนักงานสอบสวนควบคุมผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน (พนักงานอัยการมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหา โดยในกรุงเทพมหานครให้มอบตัวผู้ต้องหาให้อยู่ในความควบคุมของพนักงานสอบสวน ส่วนในต่างจังหวัดให้มอบตัวผู้ต้องหาให้แก่พัสดิควบคุมไว้ในเรือนจำตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ข้อ 2) ต่อมาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2539 มาตรา 4 ได้ยกเลิกความเดิมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสามดังกล่าว และห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่า 48 ชั่วโมง นับแต่ผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ และจะยึดเวลาเกิน 48 ชั่วโมง เท่าที่มีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนก็ได้ ทั้งนี้รวมกันแล้วมิให้เกิน 3 วัน เป็นเหตุให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนถูกร่นระยะเวลาควบคุมผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาลงถึง 4 วัน ซึ่งในระยะเวลาแรกของการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการสอบสวนได้ โดยเฉพาะสถานีตำรวจภูธรที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากศาลมาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2539 มาตรา 5 จึงได้บัญญัติเพิ่มเติมมาตรา 89 วรรคสองว่า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเมื่อพนักงานสอบสวนร้องขอและศาลได้ไต่สวนแล้วศาลอาจสั่งขังผู้ต้องหาไว้ ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนร้องขอ โดยให้อยู่ในความควบคุมของพนักงานสอบสวนตามกำหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควร "เหตุจำเป็น" ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89 วรรคสอง นอกจากตัวอย่างเพื่อให้พยานชี้ตัวดังปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเลขนี้แล้ว ยังอาจรวมถึงการกระทำการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้นด้วย อาทิ การนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประทุษกรรมการนำตัวผู้ต้องหาไปนำชี้ที่เกิดเหตุ การนำตัวผู้ต้องหาไปถ่ายรูปและบันทึกประวัติ การนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนเพิ่มเติม การนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนขยายผล หรือการนำตัวผู้ต้องหาออกนอกพื้นที่ที่ทำการเพื่อตรวจค้นตามกฎหมายค้น

ตั้งที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ การพิจารณาถึง "เหตุจำเป็น" ดังกล่าว ไม่ว่าผู้ต้องหาจะคัดค้านหรือไม่ผู้เขียนเห็นว่าศาลมีอำนาจที่จะไต่สวนถึงการสอบสวนที่ดำเนินการมาแล้วและที่จะดำเนินการต่อไปพนักงานสอบสวนเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องแสดงให้ศาลเห็นถึงเหตุจำเป็น และศาลมีอำนาจที่จะค้นคว้าหาความจริงถึงเหตุที่อ้างว่าจำเป็นเพิ่มเติมได้ อาทิ ขอตรวจดูสำนวนการสอบสวนที่ทำมาแล้วทั้งหมด หรือให้แถลงเหตุจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคำร้องขอฝากขังได้ เพราะมีฉะนั้นศาลก็มีอาจทราบได้ว่ามีเหตุจำเป็นที่สั่งขังผู้ต้องหาไว้ ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนร้องขอเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนจริงหรือไม่เพียงใด อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะสั่งขังผู้ต้องหาไว้ ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนร้องขอโดยให้อยู่ในความควบคุมของพนักงานสอบสวนตามกำหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89 วรรคสองนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคห้า ถึงวรรคแปดด้วย กล่าวคือ ต้องไม่เกิน 7 วัน หรือครั้งละไม่เกิน 12 วัน แล้วแต่อัตราโทษมากน้อยตามที่กฎหมายกำหนด และคำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ขังผู้ต้องหาไว้ ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนร้องขอเพราะเห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็น หรือคำสั่งศาลที่อนุญาตแต่ให้ขังผู้ต้องหาได้น้อยกว่ากำหนดเวลาที่พนักงานสอบสวนร้องขอตามที่ศาลเห็นสมควรนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ผู้ร้องขอจะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปไม่ได้ เพราะเป็นบทบัญญัติที่ให้เป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นโดยเฉพาะและคุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ต้องถูกคุมขัง ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนร้องขอนานเกินสมควรแก่เหตุและเกินกว่าเหตุจำเป็นในทำนองเดียวกันกับที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจสั่งคำร้องฝากขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสี่ถึงวรรคแปด ดังที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1125/2496(ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่า คำสั่งศาลไม่อนุญาตให้ขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนต่อไป เพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นนั้น ผู้ร้องขอให้ขังจะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปไม่ได้ มนต์ชัยชนินทรลีลา